

1001425-20.2022.8.26.0634

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Estaduais

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... valores configura a cobrança sobre o tráfico jurídico, baseado no contrato, o que é vedado.

As tarifas questionadas TUSD e TUST, bem como os encargos setoriais, remuneram atividades relacionadas à prestação do serviço de fornecimento pelas redes básica e especial e manutenção do próprio sistema.

São atrelados aos meios utilizados para a prestação do serviço, daí o não cabimento

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001425-20.2022.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001425-20.2022.8.26.0634

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Estaduais

Requerente:

Oscar Agostinho

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

VISTOS.

Relatório dispensado com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.

Examinados os autos, decido.

Não é o caso de suspensão do processo por força do IRDR nº 2246948-

26.2016.8.26.0000 - tema 986, uma vez que o CPC determina que, superado o prazo de julgamento do IRDR em ano, cessa a suspensão dos processos. E no caso dos autos, a suspensão acerca da matéria afetada teve início em 2017, tudo com vistas à garantia dos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da economia e celeridade processual (CF, art. 5º, inciso LXXVIII; e CPC, art. 4º e 6º). Dessa forma, se o caso, levante-se a suspensão utilizando o código próprio (55555).

No mérito, a demanda é procedente.

Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito, para o fim de afastar da base de cálculo do ICMS a incidência das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD). Requer, ainda, a restituição dos valores pagos.

Primeiramente, insta destacar que o ICMS incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, compreendendo negócio jurídico mercantil. O artigo 1º da

Lei Estadual nº 6.374/89. Ou seja, aperfeiçoa-se com a mudança da titularidade jurídica do bem.

Nesse entendimento, para a caracterização do fato gerador do tributo pressupõe-se o efetivo consumo pelo destinatário final. O ato de preparação, produção e distribuição sejam etapas para o fornecimento de energia elétrica, não podem integrar a base de cálculo para o tributo, na ausência de previsão legal. A incidência sobre tais valores configura a cobrança sobre o tráfico jurídico, baseado no contrato, o que é vedado.

As tarifas questionadas TUSD e TUST, bem como os encargos setoriais, remuneram atividades relacionadas à prestação do serviço de fornecimento pelas redes básica e especial e manutenção do próprio sistema.

São atrelados aos meios utilizados para a prestação do serviço, daí o não cabimento de sua consideração na base de cálculo do tributo.

Nesse sentido:

"ICMS. Energia elétrica. Tarifas de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) - Inocorrência de hipótese de incidência que admita utilização dessas tarifas na base de cálculo do imposto. Inexistência de "circulação" de mercadoria. Precedentes. Legitimidade ativa para a repetição. Impossibilidade de condenação em pagamento de honorários contratados com advogado. Recurso fazendário improvido, e recurso da empresa autora parcialmente provido." (Apelação nº 1009577- 98.2015.8.26.0053, rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 14/12/2015).

"APELAÇÃO. Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito. ICMS. Transmissão de energia elétrica Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia Elétrica" TUSD e TUST e encargos de conexão Sentença que julgou procedente a demanda Alegação de ilegitimidade ativa e custo operacional do sistema que deve ser suportado por quem o utiliza Pretensão de improcedência da ação - Inadmissibilidade Transmissão e distribuição de energia elétrica que não compõem o fato gerador do ICMS Legitimidade da empresa autora pacificada em recentes decisões do E. STJ Sentença de primeiro grau que será mantida- Recurso desprovido." (Apelação nº 1019266-69.2015.8.26.0053, rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j.11/04/2016).

Sobre o tema, temos a Súmula nº 391 do E. STJ: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada".

Para tanto, há circulação econômica com transferência da propriedade da energia elétrica apenas no momento em que esta é efetivamente consumida pelo destinatário, o que não ocorre na fase de transmissão e distribuição, que são etapas necessárias à prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, mas não a prestação em si.

Portanto, pelo todo exposto acima, forçoso concluir pela ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os valores referentes à TUST e TUSD e demais encargos setoriais, porquanto estão fora do âmbito do tributo.

Do pedido de restituição das quantias pagas. Sendo indevida a cobrança efetivada, de rigor a restituição do valor indevidamente cobrado e pago.

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: I - DECLARAR a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes que obrigue o autor a proceder ao pagamento do ICMS incidente sobre os valores devidos a título de TUST e TUSD, na instalação elétrica de nº 40453634, definindo-se a base de cálculo do referido tributo como sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente consumida, devendo a ré se abster de praticar medidas coercitivas relativas à referida cobrança; II - CONDENAR a ré na restituição do valor indevidamente cobrado, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença, referente à inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) de energia elétrica das mencionadas instalações, respeitada a prescrição quinquenal e desde que comprovados os respectivos recolhimentos, acrescidos de correção monetária e juros de mora como acima exposto.

Sobre o saldo apurado deverá incidir correção monetária desde o desembolso de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP até o trânsito em julgado e, a partir de

então, deverá ser aplicada a taxa SELIC (que abrange os juros de mora e correção monetária), conforme decidido pelo C.STJ no Recurso Especial nº 1.111.189/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 19) e consoante art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ ("Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"), pois, tratando-se de repetição de indébito tributário não tem incidência a Lei 11.960/09. Sem condenação em custas e honorários, nos termos da lei 9.099/95.

Fica consignado que o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no Juizado Especial Cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º. da Lei 11.608/2003, sendo no mínimo 5 UFESPs para cada parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo do recolhimento do porte de remessa e retorno.

P.I.C., e oportunamente, arquivem-se ou autos com as cautelas de praxe.

Tremembe, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA